

TRABAJO NOCTURNO

La regulación del trabajo nocturno en nuestro país ha sido regulada por la ley 19.313 y el decreto 234/015.

Los funcionarios públicos que se desempeñan en la Administración Central se encuentran regidos, en lo que respecta al concepto de trabajo nocturno y a su retribución por la ley n.º 19.121 y el decreto n.º 169/014.

La ley n.º 19.313 establece un concepto legal limitado de trabajo nocturno: En su art. 4 expresa que se considerará trabajo en horario nocturno el que se realiza «por más de cinco horas consecutivas por jornada de labor», en la franja de «22 horas y las 6 horas del día siguiente», concepto reiterado en el art. 1 del decreto reglamentario, por lo cual «no todo trabajo realizado de noche es relevante a los efectos de la ley»

La ley reglamentada establece las siguientes condiciones para que el tiempo de trabajo sea considerado como trabajo nocturno: •Desarrollar una labor por más de cinco horas consecutivas por jornada. •Entre las 22 y las 6 del día siguiente. El decreto añade un nuevo requisito: «que se desempeñe por indicación del empleador»

Trabajadores no aptos para desarrollar trabajo nocturno El art. 6 del decreto prevé el cambio de tareas para aquellos trabajadores no aptos para desarrollar el trabajo nocturno: «(Alternativas para no aptos). Los trabajadores que realicen trabajo nocturno y que por razones de salud no puedan seguirlos desempeñando, serán asignados, cuando sea factible, a un puesto similar en horario diurno».

Compartiendo la opinión del Dr. Larrañaga, consideramos que (y sin perjuicio de la opinabilidad del tema) la sobretasa del 20 % estaría sujeta a la condición del desarrollo de actividades en horario nocturno. Consecuentemente en principio creemos que el trabajador relocalizado en horario diurno no tendría derecho a mantener la percepción de la sobretasa.

El art. 2 de la ley 19.313 establece que «a la mujer grávida o que ha dado a luz, hasta un año posterior a su alumbramiento, se le asignará horario de trabajo diurno por parte del empleador, por la sola voluntad de la trabajadora, sin que esto signifique pérdida de la compensación por trabajo nocturno». El decreto reglamentario en su art. 7 expresa que el empleador deberá acceder a la solicitud, aclarando que la situación del art. 2 debe encuadrarse en el concepto de nocturnidad que da la ley (más de 5 horas de trabajo, en la franja de 22 a 06). La

norma agrega que el empleador «dispondrá de un plazo de veinte días corridos para dar cumplimiento al cambio peticionado, el que se computará a partir que tuviera conocimiento de la opción por medio fehaciente». El plazo de 20 días comenzará a contarse a partir «de que tuviera conocimiento de la opción por medio fehaciente», con lo cual en caso que no se haya podido comunicar la opción al empleador por las razones que fueren, el plazo primario de 20 días se continuará extendiendo. El problema que ni la ley ni el decreto resuelven, es la situación en la que el empleador que no puede otorgar a la trabajadora un trabajo en horario diurno. Tampoco indican las normas cual es la sanción si transcurre los 20 corridos y no hay cumplimiento: ¿deberá la trabajadora continuar trabajando en horario nocturno —con los riesgos a la salud para ella y para la criatura que ello implica— luego de los 20 días? ¿Podrá el empleador excusarse de que su establecimiento no tiene trabajo en horario diurno? Con relación al punto, el Convenio n.º 171 (no ratificado) plantea tres opciones en su artículo 7: a) asignación a un trabajo diurno cuando sea factible; b) el suministro de prestaciones de seguridad social; o c) la prórroga de la licencia por maternidad. La ley 19.313 sólo hizo referencia a la primera posibilidad, pero sin dar una respuesta en caso de que el cambio de tareas no sea posible. Ante la pregunta planteada, compartimos la opinión de Loustaunau, quien —luego de recordar el resguardo del Convenio 171 («cuando sea factible») — en tiende que el empleador no está obligado a realizar el cambio «dado que se le estaría imponiendo legalmente el cumplimiento de un hecho imposible y ello es contrario a derecho»

Debe también recordarse —como lo indican Ameglio y López— la ley n.º 17.215, que reconoce el derecho para toda trabajadora de la actividad pública o privada, en estado de gravidez o en período de lactancia, de obtener un cambio temporal de las actividades que desempeña, si estas pueden afectar su salud o la de su hijo. Si el empleador no accede al cambio de tareas, la trabajadora tiene derecho a una licencia especial, durante la cual percibirá del Banco de Previsión Social la mitad del salario que estuviere percibiendo. Finalizada la licencia, la trabajadora debe ser reintegrada a su función anterior, salvo que por acuerdo de partes se disponga lo contrario

Los referidos autores opinan que en el caso del trabajo nocturno, «el salario de la trabajadora no puede ser afectado, por lo que debería recibir su salario íntegramente o una prestación de seguridad social, durante el período en que no trabaja, similar al subsidio por maternidad. La ley n.º 17.215 sólo habilita a la trabajadora a recibir del BPS «la mitad del salario que estuviera percibiendo» en

caso que el empleador se niegue de manera fundada a realizar el cambio de tareas». Zubillaga con similares fundamentos entiende que en función de que «la ley 19.313 no prevé la posibilidad del empleador de negarse al cambio de horario, si este estuviera imposibilitado de brindar un trabajo en horario diurno y efectivamente el BPS abonara el subsidio señalado, igualmente el empleador estaría obligado al pago de la mitad del salario (que complementa el subsidio abonado por la seguridad social), ya que la imposibilidad de la trabajadora de prestar sus tareas no es en este caso atribuible a ella, por lo que no debería verse perjudicada en forma alguna». Como conclusión, consideramos que la empresa no se encuentra obligada a asignar tareas en horario diurno a la trabajadora grávida, cuando fácticamente es imposible. Al no desarrollar tareas, tampoco sería posible exigir al empleador como contrapartida el pago del sueldo. La modificación *in pejus* del salario implicaría un despido indirecto. En tendemos entonces, junto con Ameglio y López, que «la respuesta debe venir a través de la Seguridad Social, ya que no puede ser un costo a asumir por el empleador». Finalmente, sea cual sea la solución a la cual se arribe, como atinada mente lo indica Raso, «la ley tendrá el efecto indeseado de desestimular a los empleadores en la contratación de trabajadoras en edad de procrear para la realización de trabajos nocturnos»

El art. 3 de la ley 19.313, en un texto particularmente confuso, expresa: «Se establece una sobretasa mínima del 20 % (veinte por ciento) para las distintas áreas de actividad o equivalente en reducción horaria en aquellos casos que no lo tengan comprendido en su salario específico o en su forma de remuneración establecido de acuerdo al laudo, un porcentaje igual o superior a esta. Cuando la compensación sea menor se ajustará al mínimo establecido en la presente ley. Lo mismo se aplicará en los casos de reducción horaria. Los Consejos de Salarios podrán fijar porcentajes mayores a la sobretasa mínima establecida anteriormente». Ante las críticas del texto legal, el decreto reglamentario ofrece una solución más clara en su art. 8: «(Base de cálculo). A los efectos de lo dispuesto en el art. 3.º de la ley n.º 19.313 la sobretasa mínima del 20% (veinte por ciento) se calculará sobre el salario básico que perciba el trabajador. Para el caso de remuneración por comisiones o destajo, el salario básico deberá determinarse por el promedio de lo percibido en cada jornada». Agrega el art. 9, que «una vez que se superen las cinco horas consecutivas de labor en el lapso de 22 a 6 hs, se aplicará la sobretasa del 20 % sobre todo el tiempo trabajado en el rango horario referido. A estos efectos, el tiempo de descanso en la jornada continua se considera trabajo nocturno si se cumple en el horario señalado

precedente mente». El decreto aclara así las posibles dudas sobre la base de cálculo de la sobretasa del 20 %.

En caso de realizarse horas extra en la jornada nocturna, en lo que respecta a la base de cálculo de las mismas, la posición no es unánime.

«La primera de ellas, que podemos denominar restrictiva, es la que también puede calificarse como la más «piedeletrista» que sostiene que para el cálculo del recargo correspondiente a la hora extra se debe considerar únicamente el valor hora considerando el salario base»; La segunda, que llamaremos amplia, que sostiene que para la base de cálculo del recargo del valor de la hora extra se debe considerar toda partida que perciba el trabajador siempre y cuando la misma posea carácter salarial». Y finalmente la tercera posición que podemos denominar intermedia, cuyos seguidores sostienen que para el cálculo del recargo correspondiente a la hora extra se deben considerar además del salario base únicamente aquellas partidas salariales que estén dirigidas a remunerar el trabajo del empleado considerado en unidades hora».

El art. 11 establece: «La opción por la sobretasa del 20 % o su equivalente en reducción horaria se resolverá por decisión unilateral del empleador, sin perjuicio de los mecanismos de negociación colectiva que pudieran implementarse».